Índice

Introdução 2

Objectivos 2

Objectivo Geral..... 2

Objectivos Específicos 2

Fontes do Direito Moçambicano..... 3

Classificação das fontes de direito..... 4

A Lei..... 5

A Lei: Sentidos da palavra..... 5

O Costume..... 6

Definição 6

Elementos do costume..... 7

Espécies de costume..... 8

A Jurisprudência..... 9

Conceito 9

A jurisprudência como fonte de produção da norma..... 9

Relação do costume com a lei 10

Conclusão 12

Referências Bibliográficas..... 13

1. Introdução

O presente trabalho tem por objecto as Fontes do Direito. A sua pertinência é indubitável, por se tratar do problema de saber a origem das normas jurídicas, ou seja, a questão de saber o modo como certas normas ascendem à categoria de norma jurídica. Problema esse, que para quem queira ter as noções gerais de direito, importa reflectir de forma a conhecer as fontes do direito. Assim sendo, analisar e expor as fontes do direito, ainda que de forma singela, constitui o objectivo principal do presente trabalho. Para a feitura do presente trabalho, optámos por uma consulta e análise da melhor doutrina sobre o tema.

Portanto, abordaremos, de forma clara, sem o escopo de esgotar o tema, muito pelo contrário, mas sim, abrir uma discussão acadêmica, do ponto de vista científico, como aplicar essa ferramenta de solução dos problemas e seguiremos a linha de pensamento: Iniciaremos com as fontes do direito, especialmente o costume.

1.1. Objectivos

1.1.1. Objectivo Geral:

- Compreender sobre costumes e a jurisprudência do direito em Moçambique.

1.1.2. Objectivos Específicos:

- Compreender as fontes do Direito Moçambicano e a sua classificação;
- Conhecer a lei do sentido da palavra;
- Identificar os elementos do costume;
- Conhecer a jurisprudência como fonte de produção da norma;
- Compreender a relação do costume com a lei.

2. Fontes do Direito Moçambicano

O problema da criação do Direito tem a ver com fontes do Direito. E o problema da evolução tem a ver com as transformações ou metamorfoses que o Direito sofre ao longo da história. Assim, podemos definir que são fontes do Direito os modos de formação e revelação das normas jurídicas. As fontes do Direito Moçambicano são as mesmas de qualquer País do sistema Romano-Germânico que são designadamente:

- **A lei**: norma jurídica criada e imposta por uma autoridade com poder para o fazer (poder legislativo).
- **O costume:** norma jurídica resultante da prática repetida e habitual de uma conduta encarada como obrigatória.
- **A jurisprudência:** orientações que, em matéria de determinação e aplicação da lei, decorrem da actividade prática de aplicação do direito pelos órgãos da sociedade para tais encarregados (os tribunais).
- **A doutrina**: actividade de estudo teórico dogmático do direito. São fontes do direito as origens do direito, ou seja, o lugar ou a matéria prima pela qual nasce o direito. Estas fontes podem ser materiais ou formais.

As fontes formais imediatas são as normas legais. Importa observar que um dos mais importantes princípios de direito, no âmbito fiscal, é a disposição constitucional que estabelece que «os impostos são criados ou alterados por lei, que os fixa segundo critérios de justiça social» vide art. 100 CRM. Isso quer dizer que se não existir uma norma legal que defina como são criados os impostos, não haverá outra norma que pune as infracções fiscais.

As fontes formais mediatas são os costumes, os princípios gerais do direito, a jurisprudência e a doutrina.

Do exposto, vai resultar a distinção das **fontes de direito em sentido formal** e **material**.

- Designam-se **fontes de direito em sentido formal**, os factos normativos a que o sistema jurídico imputa o efeito de pôr ou positivar normais juridicamente vinculantes. Nesta senda, fontes de direito em sentido formal ou técnico-jurídico serão os modos de criação e revelação de normas jurídicas.

- **Fontes de direito em sentido material**, são elementos que emergem da própria realidade social e dos valores que inspiram o comportamento a ser tutelado e que levam ao vislumb rede um direito, ou seja, segundo João Baptista Machado, são factores ou poderes sociais de facto que causalmente originaram ou influíram o processo de produção normativa. Para o nosso estudo, interessa fontes de direito em sentido formal ou técnico-jurídico. Dito doutro modo, interessa-nos fontes de direito enquanto modos de criação e revelação de normas jurídicas.

2.1. Classificação das fontes de direito

São várias as classificações das fontes de direito, essa variedade resulta do facto de competir a cada direito positivo a definição das suas próprias fontes. Em Moçambique, o legislador estabeleceu nos artigos 1º a 4º do Código Civil disposições sobre Fontes de Direito. Segundo os referidos dispositivos do Código Civil são fontes imediatas do direito apenas as leis e as normas corporativas que não contrariem as disposições legais de carácter imperativo.

No artigo 2º, o legislador reconhece ao poder judicial a competência para, nos casos declarados na lei, fixar por meio de assentos doutrina com força obrigatória geral. Esta competência é exercida pelo Tribunal Supremo. E no artigo 3º, o costume é reconhecido como fonte mediata de direito, quando não contrarie os princípios da boa fé.

Por sua vez, no artigo 4.º ainda do Código Civil, os tribunais podem recorrer à equidade quando haja disposição legal que o permita, quando exista acordo das partes e a relação jurídica não seja indisponível, ou ainda quando as partes tenham convencionado o recurso à equidade numa cláusula compromissória.

De todo o exposto, é de referir que são fontes do nosso direito a lei, o costume, a jurisprudência e a doutrina. Sendo que, a lei é indiscutivelmente a principal fonte do direito.

2.2. A Lei

A palavra lei comporta vários sentidos. É multifacetada. Podemos falar de lei para significar todo nosso sistema jurídico e toda nossa ordem jurídica. Pode ainda significar lei como qualquer ramo de Direito. Pode significar lei como o acto normativo que é legislativo propriamente dita em sentido formal que se identifica a mesma através da lei como respectiva lei, podemos falar lei a mesma determinada regra ou norma.

No nosso estudo importa-nos referir lei em sentido formal que designa aquilo que se chama a actividade legislativa propriamente dita, ou seja, a actividade exercida por determinado ou determinados órgãos oficialmente qualificados. Esses órgãos constituem o que se chama o poder legislativo que é **AR- Assembleia da República**.

2.2.1. A Lei: Sentidos da palavra

Lei em sentido material é toda disposição provinda de uma autoridade competente. Assim sendo, a lei vai desde a Constituição da República até aos assentos do tribunal supremo, passando pelas leis ordinárias e os regulamentos. Deste modo, lei em sentido material abrange a Lei propriamente dita da Assembleia da República, o Decreto-Lei do Conselho de Ministros, o Decreto Presidencial e o Decreto do Conselho de Ministros e o Diploma Ministerial.

Como se denota, embora varie o órgão que faz a lei e a forma porque a faz, permanece idêntica a matéria, isto é, o conteúdo da lei é sempre o mesmo, que é no caso, uma regra jurídica geral e abstracta emanada do Estado em sentido amplo, abrangendo qualquer pessoa colectiva de direito público.

Em sentido formal, a lei designa aquilo que se chama a actividade legislativa propriamente dita, ou seja, a actividade exercida por determinado ou determinados órgãos oficialmente qualificados e segundo forma solene estabelecida na Constituição. Assim sendo, podemos afirmar que lei em sentido formal é a disposição provinda de um órgão com poder legislativo, e segundo a Constituição da República esses órgãos são a Assembleia da República, quando actua produzindo leis propriamente ditas, e o Conselho de Ministros, quando produz decretos-lei.

No entanto, a lei tem outros sentidos, podendo designar todo ordenamento jurídico; como Constituição da República; como determinado ramo de direito consubstanciado ou não em um código; e como uma determinada regra contida num determinado artigo. Portanto, o sentido exacto de lei só é aferido como tal segundo o contexto que estiver inserido.

A lei em sentido formal obedece a um processo próprio de elaboração que consta em certos países da respectiva constituição e em outros do regimento da Assembleia da República ou do parlamento. Entre nós, este processo consta, não do texto constitucional, mas, do regimento da Assembleia da República.

2.2.2. **Os Assentos do Tribunal Supremo**

Entre nós, o Tribunal Supremo pode, ao resolver um conflito de jurisprudência e verificados certos pressupostos, fixar doutrina com força obrigatória geral, ou seja, editar normas sob a forma de Assentos que, uma vez publicados no Boletim da República, vinculam todos os tribunais, assim como todas as demais pessoas e entidades. Desse modo, os Assentos são fontes mediatas do direito.

Desse modo, pode-se afirmar que os Assentos podem ser fontes interpretativas, se se limitam a fixar o sentido de certa norma de alcance ambíguo, ou, fontes inovadoras, se vêm preencher uma lacuna do sistema jurídico.

2.3. O Costume

2.3.1. Definição

São vários os autores que definem o costume. Para Maria Helena Diniz, costume é uma norma que deriva da longa prática uniforme ou da geral e constante repetição de dadocomportamento sob a convicção de que corresponda a uma necessidade jurídica. Por sua vez, Ulpiano entende o costume como o tácito consenso do povo, reiterado por longo tempo.

Para Paulo Nader, o costume é um conjunto de normas de conduta social, criadas espontaneamente pelo povo, através do uso reiterado, uniforme e que gera a certeza de obrigatoriedade, reconhecidas e impostas pelo Estado.

O costume que deve ser objecto do estudo do direito é o costume jurídico, como seja, Aquele capaz de gerar direitos e obrigações. O costume sem esta essência é o costumeapenas de convivência social, sem nenhuma repercussão no mundo jurídico.

Dos conceitos supra, podemos definir o costume como normas de direito que surgem por motivos práticos da sociedade, quando, na ausência da norma legal específica adetermina da situação, a necessidade de disciplina leva o povo a criar regras não escritas que, assimiladas de forma geral e por grande período de tempo, ganham carácter de efectividade e passam a merecer o respeito daqueles que a utilizam, o que conduz a serem prestigiadas e observadas pelo Estado. Numa definição simples, podemos dizer que o costume é uma prática reiterada com convicção de obrigatoriedade.

2.3.2. Elementos do costume

- **Elemento material** ou ***corpus*** traduz-se na observância generalizada e uniforme, com certa duração, de determinado padrão de conduta em que está implícita uma norma.

Assim, o costume deve ser geral, uniforme e dotado de certa estabilidade no tempo. A generalidade não quer significar prática adoptada por todo o povo, mas sim, por um círculo de pessoas unidos no mesmo território, profissão ou ainda por outros factores. A uniformidade representa a necessidade de um consenso geral do povo, sem insurgências ao comando da regra costumeira e à sua necessidade.

Certa estabilidade no tempo verifica-se o costume pelo longo período de tempo em que ele se faz presente no *opinio* popular, período razoavelmente longo, a se aferir pelo bom senso.

- **Elemento Psicológico** ou ***animus*** **O *animus*** é a tal convicção de obrigatoriedade, ou seja, a convicção de que a norma é necessária, imprescindível às relações sociais, daí o desejo de que seja mantida em sua eficácia (*opinio júris et necessitatis*).

2.3.3. Espécies de costume

O costume pode dividir-se tendo por base a sua extensão. Assim, teríamos costume nacional, quando se alarga a todo território do Estado, e costume local, quando é restrito acerta região. Ainda tendo por base a sua extensão, haverá costume que se estende a uma generalidade de relações ou se limita num ramo particular de actividades. No entanto, a classificação mais importante é aquela que assenta na relação entre o costume e a lei.

Desta classificação teremos, o costume, **secundum legem**, **praeter legem** e **contra legem**.

- **Costume secundum legem**, num primeiro sentido é o costume que se consagra no meio social sem discrepância a ordem, em seus aspectos éticos e axiológicos, daí que muitas vezes passa ao domínio escrito convertendo-se em lei.

Num segundo sentido, é o costume que, conservando a sua forma não escrita, é reconhecido pelo legislador como preceito íntegro, daí que a lei recomenda que seja observado. Em linhas gerais, podemos afirmar que o costume secundum legem é o conforme com alei, ou seja, está em conformidade com uma lei que interpreta, daí também ser designado por costume interpretativo.

- **Costume praeter legem**, é o costume que se reveste de carácter supletivo da norma, pois acha-se para além da lei, suprindo-a nos casos omissos ou lacunas. Esses costumes não eram contraditórios com a lei, e nem conformes com a lei que interpretassem, mas sim estavam para além de todas as leis existentes, daí serem costumes *praeter legem.*
- **Costume contra legem** é a espécie de costume que se concretiza em contrário a expressão da lei. Nele se apresentam os casos do consuetudo ab-rogatório, que implicitamente revogatório do preceito a que se contrapõe e do desuetudo, que consiste a não aplicação da lei em virtude do desuso, quando a realidade é mais forte que o preceito legal, o que a torna, no dizer jurídico, uma letra morta.

Entretanto, o artigo 7 do Código Civil exclui essa possibilidade de cessação de vigência das normas jurídicas.

2.4. A Jurisprudência

2.4.1. Conceito

Etimologicamente, a palavra jurisprudência, de origem latina, significa: júris (direito) +prudentia (sabedoria).

A doutrina vai no sentido de entender a jurisprudência como forma de revelação do direito que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmónica de decisões dos tribunais.

No entanto, pode-se definir jurisprudência como o entendimento dos magistrados, exteriorizados em sentenças ou acórdãos, no qual manifestam, de forma harmónica, conhecimento acerca do direito aplicado a um caso concreto, cujos fundamentos das decisões são colocados à disposição da comunidade jurídica através de publicações, servindo como base a pesquisa em contribuição ao saber jurídico.

2.4.2. A jurisprudência como fonte de produção da norma

De um modo geral, em face ao princípio fundamental da "tripartição de poderes" em legislativo, executivo e judicial, os tribunais não tem função normativa, e, assim, jamais haver-se-á de conceber que as suas decisões se equivalham ao imperativo de uma lei, daí pode se dizer que, em sua acepção técnica, "jurisprudência não é norma".

Entretanto, ocorre que a interpretação dos tribunais, pela sua natureza científica, pode servir de base ao legislador, tanto para a instituição do direito ainda não contemplado pela ordem, quanto ao melhoramento desta. Na sua tarefa integradora, no sentido de completar a lei em face a um caso concreto, com o objectivo de apenas aplicar o direito, porém, dada a repercussão de um julgado, a sociedade o toma como um grande avanço, daí ser óbvio que a ressonância vá bem mais além da comunidade jurídica criando consciência de valor nos órgãos legislativos.

Desse modo, a jurisprudência tanto serve para a "aplicação da norma" ao interpretar o direito, quanto pode dar uma luz ao legislador e, assim, contribuir para o aperfeiçoamento da ordem jurídica, com a "criação da norma" pertinente aquela situação.

Em Moçambique, quando falamos de jurisprudência como fonte de direito, quer significar o conjunto das decisões do Tribunal Supremo, mas nem todas as decisões, apenas as que têm o nome de Assentos.

Portanto, os Assentos são decisões do Tribunal Supremo que fixam doutrina com força obrigatória geral, ou seja, passam a ser lei de cumprimento obrigatório para todos os tribunais subordinados ao Supremo. Assim sendo, os Assentos constituem o único actonormativo que não provém dos órgãos do Estado (órgãos da função legislativa ouexecutiva), mas sim dos tribunais.

O Tribunal Supremo emite Assentos quando reunido em plenário para apreciar os seus próprios acórdãos ou quando haja contradição entre dois ou mais acórdãos sobre a mesma questão de direito.

2.5. Relação do costume com a lei

Em relação às leis, três são as espécies de costume: *secundum legem*, *praeter legem* e *contra legem*.

O costume ***secundum legem*** está previsto na lei, que reconhece sua eficácia obrigatória. No nosso direito tal é o caso do: a) art. 597 do Código Civil que dita: "A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações" e, b) art. 615 que afirma: "Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza". É óbvio que nesses casos o preceito costumeiro não se encontra contido na lei civil, mas é por ela admitido.

O costume é ***praeter legem*** quando se reveste de caráter supletivo, suprindo a lei nos casos omissos, preenchendo lacunas. Esse costume é invocado, quando não se puder empregar a argumentação analógica, nas hipóteses de silêncio da lei sobre determinado assunto, procurando preencher esse hiato legal pela observância de práticas consuetudinárias.

Entretanto, muitas pessoas vêm, reiterada e ininterruptamente, emitindo-o não como uma mera ordem de pagamento mas como garantia de dívida, para desconto futuro, na convicção de que esse procedimento não constitui crime.

Tal costume de emitir cheque pós-datado, baseado em hábito da época, realizado constante e uniformemente e na convicção de que se trata de uma norma jurídica, como se fosse um sucedâneo de letra de câmbio ou de promessa de pagamento, faz com que o magistrado utilize-se dessa norma consuetudinária como fonte supletiva da lei, declarando a inexistência do crime.

O costume ***contra legem*** é aquele que se forma em sentido contrário ao da lei. Seria o caso da *consuetudo abrogatoria*, implicitamente revogatória das disposições legais, ou da *desuetudo*, que produz a não-aplicação da lei, em virtude de desuso, uma vez que a norma legal passa a ser letra morta.

3. Conclusão

De todo o exposto, torna-se importante referir que fontes de direito são modos de criação e revelação de normas jurídicas. E o problema da sua determinação releva para sabermos como é que determinados conteúdos normativos ascendem a juridicidade. Nesta senda, são fontes de direito a lei, o costume, a jurisprudência e a doutrina. A lei é a principal fonte de direito. Sendo que, o termo lei deve ser entendido como toda disposição provinda de uma autoridade competente.

Por sua vez, o costume só é fonte de direito quando a lei o determinar, daí que se trata de uma fonte mediata. No que tange a jurisprudência, ela só é fonte de direito, quando se trata de uma decisão do Tribunal Supremo, na forma de assento. A terminar, cumpre salientar que a doutrina só é fonte de direito voluntária, pois tudo depende da força dos seus argumentos em convencer o legislador e este assumindo-a em transformar em lei. Assim sendo, o direito é criado e revelado através da lei, costume, jurisprudência e doutrina. O seu conhecimento torna-se, assim, peculiar para quem pretende ter alguma noção do direito.

Chegamos à conclusão, nesse ínterim que a legislação imposta pelo Estado se sobrepõe aos costumes, assim podemos induzir que num primeiro momento temos os costumes como regras, porém, num segundo momento, com interesses de grupos ou pessoas, o Estado é formado, criando, desta forma, a lei positiva. Desta feita, enxergamos com precisão que a lei imposta pelo estado "abafa" os costumes, sob o fundamento de ser uma no rma de todos, com extensão maior do que os costumes.

Referências Bibliográficas

ASCENÇÃO, J. Oliveira; *O Direito – Introdução e Teoria Geral* ; Lisboa; 2001.

MACHADO, João Baptista; *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*; Livraria Almedina; Coimbra; 2000.

TELLES, Inocêncio Galvão; *Introdução ao Estudo do Direito*; Vol. I; 10ªedição; AAFL; Lisboa; 1998.

SOUZA, Carlos Orlando Fonseca de; *Fontes do Direito;* Disponível em:www.pontojuridico.com